

1500301-37.2021.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... pelo local, já conhecido como ponto de tráfico, quando ali avistaram o réu Marcelo, vulgo Ceceu, nas proximidades do galpão pertencente à empresa Ludival. Marcelo encontrava-se na companhia do réu Herbert, e ambos foram vistos realizando movimentação típica do tráfico, qual seja, manterem contato com terceiros, deslocarem-se da frente do bar de Herbert até a entrada do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500301-37.2021.8.26.0550 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500301-37.2021.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241537/2021 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 20051752 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 194/21/616 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2241537 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Herbert Rafael Corveloni Pedroso e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Herbert Rafael Corveloni Pedroso, e Marcelo Henrique Romanelli Zerbo, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 108/110.

Ambos os réus foram presos em flagrante. A decisão de fls. 50/52, concedeu ao réu Herbert o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto a Marcelo Henrique, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Oferecida a denúncia, os acusados foram regularmente notificados nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 141 e 143), e apresentaram suas respectivas defesas preliminares (fls. 150/151 e 169/170), ambas por meio da Defensoria

Pública.

A denúncia foi recebida no dia 03 de fevereiro de 2022, nos termos da decisão de fls. 176/182.

A Defensoria juntou ainda os documentos de fls. 215/230.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas quatro testemunhas comuns, e interrogados os réus.

Em memoriais de fls. 239/242, o Ministério Público requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A Defensoria Pública, em memoriais de fls. 248/273, requer a total improcedência da ação penal, alegando que os réus negaram qualquer envolvimento com a droga encontrada no prédio próximo ao bar de propriedade do acusado Herbert. Alega ainda que o acusado Marcelo encontrava-se apenas bebendo na frente do bar, e que também desconhecia a existência do entorpecente no interior do barracão próximo de onde foram abordados. Alega que nada de ilícito foi encontrado com os acusados, e que a prova acusatória limita-se aos depoimentos dos policiais civis e militares que participaram da diligência. Afirma que, ao contrário do que disseram os policiais, o réu Herbert mantinha um bar em funcionamento no local, e que os 3.000 eppendorfs vazios foram encontrados no interior do galpão, e não no bar mantido por Herbert. Por outro lado, segundo os policiais, os acusados sequer foram vistos ingressando no galpão onde a droga foi encontrada, e também nem um suposto usuário foi abordado para que pudesse corroborar as denúncias de tráfico no local. Aduz ainda que o galpão em questão é todo cercado por muros e portões, além de possuir sistema de monitoramento 24 horas, de modo que os acusados não possuíam liberdade de acesso ao seu interior. Enfim, conclui a Defensoria no sentido de que não há indício algum que vincule os réus ao entorpecente apreendido no interior do galpão. Em caso de condenação, requer que as penas base sejam fixadas no mínimo legal, a incidência da causa de diminuição previstas no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se aos réus Herbert Rafael Corveloni Pedroso, e Marcelo Henrique Romanelli Zerbo, a prática do crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 03 de setembro de 2021, por volta de 10h43min, policiais civis da DISE realizavam campana nas proximidades do endereço localizado na rua 17, n. 9999, Parque Universitário, nesta cidade de Rio Claro, diante da existência de notícias de que um prédio abandonado que há no local, pertencente à empresa Ludival, era utilizado como depósito de entorpecentes. Durante a campana, os policiais civis teriam visto ambos os réus nas proximidades, realizando a venda de entorpecentes.

Simultaneamente à campana da Polícia Civil, policiais militares também foram solicitados a comparecer no local, pois receberam a informação de que dois indivíduos estavam no local realizando o comércio de entorpecentes. Os policiais militares receberam as características das vestes utilizadas por um dos indivíduos, as quais coincidiam com as das roupas usadas pelo réu Herbert.

Realizada a abordagem dos acusados, com Herbert, no bolso de sua bermuda, foi encontrada a quantia de R\$ 89,00.

Efetivadas buscas pelo interior do imóvel mencionado, pertencente à empresa Ludival, foram encontradas 184 porções de maconha, pesando cerca de 964 gramas, 03 tijolos de maconha, pesando 4,360 Kg, e ainda 236 porções de cocaína, pesando aproximadamente 285 gramas.

Realizadas buscas no interior do bar de Herbert, situado defronte ao galpão onde a droga foi apreendida, foram localizados sacos plásticos utilizados para o embalamento da droga, tesoura, uma balança de precisão, fita adesiva, e 3.000 microtubos vazios, invólucro notoriamente usado para embalar a cocaína em porções menores. Indagados, os acusados disseram que toda a droga pertencia a um indivíduo de alcunha "Quadrado", que foi visto circulando pelo local durante a prisão em flagrante de

ambos.

Encerrada a instrução, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 18/19, que atesta a apreensão de todo o entorpecente acima descrito, cuja quantidade é expressiva, e também de outros objetos normalmente utilizados para a embalagem de entorpecentes, destacando-se a existência de nada menos do que 3.000 microtubos plásticos (ependorfs). Também foi apreendida a quantia de R\$ 86,00, conforme auto de fls. 90. O laudo de fls. 98/102, por sua vez, apresentou resultado positivo para maconha e cocaína com relação ao material apreendido no interior do barracão.

A autoria, nada obstante os doutos argumentos da Defensoria Pública, restou igualmente provada.

Interrogados em juízo, os acusados negaram qualquer vinculação com a droga apreendida.

Herbert Rafael Corveloni Pedroso, questionado a respeito dos fatos, alego que na data dos fatos encontrava-se em seu bar, que fica na frente do galpão já mencionado, e que foi até o lado de fora, oportunidade em que deparou-se com o réu Marcelo e outros indivíduos bebendo. Herbert vendeu uma cerveja e uma dose de conhaque a Marcelo, e permaneceu do lado de fora do bar. Em determinado momento, policiais civis e militares chegaram no local, e abordaram todos os presentes. Herbert foi revistado, sendo encontrada em seu poder apenas a quantia de R\$ 79,00, proveniente das vendas de seu bar. Em seguida os policiais passaram a questionar todos os presentes a respeito de seus antecedentes. Os policiais militares também revistaram sua residência e seu bar, que ficam no mesmo prédio, e nada de ilícito encontraram. Em seguida, segundo o réu, todos foram liberados, momento em que vendeu mais uma cerveja e uma dose de conhaque a Marcelo, que pagou-lhe com uma cédula de dez reais. Contudo, antes dos policiais militares deixarem o local, os policiais civis se aproximaram e solicitaram que Herbert e Marcelo permanecessem abordados. Alega que a abordagem inicial ocorreu por volta das 10 horas, e que permanecem com os policiais no local até por volta das 16 horas, quando então um policial civil chegou dizendo aos réus que "a casa caiu", e que ambos estavam presos. Alegou que chegou a ver uma sacolinha de cor amarela nas mãos de um dos policiais, mas não viu o que havia no seu interior. Afirmou que sequer chegou a ver o entorpecente que foi apreendido dentro do barracão. Herbert disse ainda que conhecia Marcelo do próprio bairro, e que ele frequentava seu bar. Alegou que seria impossível manterem drogas dentro do galpão, pois se trata de um imóvel todo fechado, de difícil acesso, e que possui monitoramento. Por fim, asseverou que na época havia sofrido um acidente de moto, de modo que não conseguia se locomover facilmente, de modo que não conseguiria ingressar no galpão escalando muros ou portões.

Já o réu Marcelo também negou a prática do delito. Alegou ter passado toda a madrugada bebendo e usando drogas, e que, ao invés de ir trabalhar, resolveu ir até o bar de Herbert, onde continuou a beber na companhia de outras pessoas. Em determinado momento, todos foram abordados por policiais militares, que nada encontraram de ilícito. Diante disso, todos foram liberados, e deixaram o local, com exceção de Marcelo, que permaneceu sentado na frente do bar de Herbert. No momento em que a última viatura da Polícia Militar deixava o local, os policiais civis se aproximaram, e solicitaram aos militares que ficassem com os réus abordados. Em seguida os policiais civis se afastaram, e retornaram algumas horas depois na posse de uma sacola, que foi colocada dentro da viatura. Marcelo e Herbert receberam voz de prisão, e vieram a saber da apreensão do entorpecente somente na Delegacia. O acusado disse ainda que é usuário de drogas, morador daquele bairro, e que o galpão mencionado permanece fechado, além de possuir vigilantes particulares.

Contudo, a versão apresentada pelos réus esbarra no restante da prova acusatória. De início, temos que a considerável quantidade de cocaína e maconha apreendida, 184 porções de maconha, pesando 964 gramas, 03 tijolos de maconha, pesando 4,360 Kg, e 236 porções de cocaína, pesando 285 gramas, por si só constitui veemente indício de sua destinação mercantil. Também foram apreendidos nada menos do que 3.000

microtubos vazios, invólucro este notoriamente usado por traficantes para dividir da cocaína em porções menores. Não há como negar, portanto, que a droga seria destinada à venda.

Também há provas que vinculam os réus ao entorpecente apreendido, senão vejamos. A policial militar Milena Campos, ouvida em juízo, afirmou que se encontrava em serviço na data dos fatos, quando sua equipe recebeu, via COPOM, a informação de que dois indivíduos encontravam-se no local já mencionado praticando o tráfico, e que um deles usava camiseta azul e bermuda. Diante disso, sua equipe foi até o local, e lá se depararam com ambos os réus, sendo que Herbert usava roupas com as mesmas características. A testemunha, importante observar, não mencionou a existência de outras pessoas que tenham sido abordadas, a não ser os dois acusados. Em revista pessoal, apenas uma quantia em dinheiro foi encontrada com Herbert. Foram realizadas buscas nas imediações, mas nada de ilícito foi encontrado. Contudo, uma pessoa teria aproximado, e comentado que Herbert seria o gerente do tráfico daquele ponto, o que foi negado pelo acusado, que disse ser apenas o proprietário de um pequeno bar. No interior do bar, que fica do outro lado da rua onde os réus foram abordados, foram encontrados apenas alguns objetos que podem ser utilizados para embalar entorpecentes, tais como balança e saquinhos plásticos. Durante a diligência, alguns policiais civis da DISE se aproximaram, e informaram a testemunha e aos demais militares, que naquele momento estavam realizando campanhas no local com o mesmo objetivo, qual seja, apurar a prática do tráfico. Os policiais civis disseram ainda que teriam visto onde os réus armazenavam a droga, mais precisamente o galpão abandonado da empresa Ludival. Em razão disso, a testemunha e seus colegas de farda permaneceram com os acusados, enquanto que os policiais civis foram até o referido galpão, onde encontraram todo o entorpecente apreendido. Durante a diligência, segundo a testemunha, um indivíduo de alcunha "Quadrado" teria passado pelo local algumas vezes, mas não foi abordado. "Quadrado", segundo o que constava, seria o "patrão" dos acusados, que foram abordados próximos ao muro do galpão onde a droga foi localizada. Milena disse ainda que não participou das buscas no interior do galpão, cujo portão, no momento de sua chegada no local, estava fechado.

Em igual sentido foi o depoimento do também policial militar Denis Aurélio Dias da Cunha, que confirmou ter ido até o local para averiguar uma denúncia de tráfico, e que se deparou com ambos os réus, que estavam sozinhos naquele momento. Herbert foi abordado na frente de sua residência, onde também funciona o mencionado bar, local onde foram encontrados alguns petrechos que podem ser utilizados para embalar entorpecentes (saquinhos plásticos). Durante a abordagem dos réus, em poder de quem nada de ilícito foi encontrado, aproximaram-se os policiais civis da DISE, dizendo que estavam realizando uma campanha na rua de trás, também com o fim de apurar a prática do tráfico naquele ponto. Denis e os demais policiais militares permaneceram com os réus abordados, enquanto que os policiais civis vasculharam o interior do galpão existente logo na frente do bar de Herbert, onde foram encontradas as porções de maconha e cocaína. Denis mencionou que, além dos réus, apenas um outro indivíduo totalmente embriagado foi abordado, mas liberado em seguida, pois nada foi apurado com relação a ele.

Já o policial civil Lucas Homero Santile, também ouvido em juízo, asseverou que o réu Marcelo, vulgo Ceceu, já vinha sendo investigado por conta de seu envolvimento com o tráfico de drogas naquele local. Na data dos fatos, durante campanha realizada nas proximidades, observou Marcelo junto ao réu Herbert, que até então não era conhecido, realizando típicos atos de venda de entorpecentes. Segundo a testemunha, os réus eram abordados por terceiros, afastavam-se na direção da entrada do barracão, e retornavam logo em seguida, consumando a transação. Em razão do local onde a campanha foi realizada, foi possível ver apenas que os réus se afastavam na direção da entrada do barracão, não sendo possível visualizar o efetivo ingresso no interior do imóvel. Diante da evidência da prática do tráfico, a testemunha e os demais policiais civis decidiram ingressar no barracão, localizar o entorpecente, e em seguida aguardar a entrada dos acusados no local. Contudo, antes disso, os policiais militares efetuaram a abordagem dos acusados. Em razão disso, foi solicitada a cooperação dos militares para que permanecessem em poder dos réus,

enquanto eram realizadas buscas dentro do galpão. Durante a diligência no interior do imóvel, foram encontrados os entorpecentes, a balança, e os 3.000 microtubos vazios. Herbert foi questionado, e disse que residia na frente do galpão, onde mantinha um pequeno bar. A testemunha disse ainda não se recordar se o galpão estava aberto ou fechado, mas confirmou ter visto ambos os réus juntos, e mantendo contato suspeito com terceiros. Marcelo, por sua vez, seria o responsável pela distribuição da droga naquele ponto do bairro Parque Universitário. Lucas também confirmou que, durante a diligência, a pessoa de apelido "Quadrado" passou algumas vezes pelo local, demonstrando nervosismo, e que seria ele o "gerente" daquele ponto, ocupando uma posição hierarquicamente superior à dos réus.

Gustavo Felipe Baptista Juliano, também policial civil da DISE, relatou em juízo que na data dos fatos passavam pelo local, já conhecido como ponto de tráfico, quando ali avistaram o réu Marcelo, vulgo Ceceu, nas proximidades do galpão pertencente à empresa Ludival. Marcelo encontrava-se na companhia do réu Herbert, e ambos foram vistos realizando movimentação típica do tráfico, qual seja, manterem contato com terceiros, deslocarem-se da frente do bar de Herbert até a entrada do galpão, e retornarem em seguida, finalizando a venda. Diante da situação, a testemunha e seus colegas resolveram ingressar no galpão e abordar os acusados. Contudo, antes disso, os policiais militares também chegaram no local, e abordaram ambos os réus. A testemunha confirmou que o bar de Herbert foi revistado, e que no local foram encontradas apenas algumas sacolinhas de plástico. Em seguida foram realizadas buscas no interior do galpão, onde toda a droga e os 3.000 microtubos foram encontrados. A testemunha confirmou que os acusados estavam juntos durante a campana, e que efetivamente foram vistos em movimentação típica do tráfico. Gustavo também confirmou que, durante a diligência, "Quadrado" passou várias vezes pelo, sendo apontado pelos réus como sendo o "patrão" do referido ponto de tráfico. A testemunha também relatou que o galpão, muito embora seja fechado, permite fácil acesso ao seu interior.

Portanto, analisada a prova oral, não há como se escapar da conclusão de que os réus praticavam o tráfico no local, e mantinham em depósito a droga apreendida no interior do galpão da empresa Ludival.

O réu Marcelo, vulgo Ceceu, já era investigado por seu envolvimento com o tráfico praticado exatamente naquele local, sendo apontado como sendo o responsável pela distribuição do entorpecente. "Quadrado", que foi visto passando pelo local durante a abordagem, seria o "patrão" de ambos os réus. Na data dos fatos, policiais da DISE passavam pelo referido ponto, quando se depararam com Marcelo próximo ao galpão abandonado, o que chamou a atenção dos agentes da lei, que resolveram realizar uma campana. Durante a observação, constatou-se que Marcelo estava acompanhado do réu Herbert. Ambos foram abordados por alguns usuários, e a movimentação que realizavam era típica do tráfico, ou seja, afastavam-se dos usuários, caminhavam na direção da entrada do galpão, e retornavam em seguida. Antes da abordagem dos policiais civis, policiais militares também foram ao local em razão de um outra denúncia de tráfico, e foram os responsáveis pela abordagem dos acusados. Apenas dinheiro foi encontrado em poder de Herbert. Diante da abordagem dos militares, os policiais civis se apresentaram, e solicitaram que aqueles permanecessem com os réus no local, enquanto vasculhavam o interior do galpão. Durante as buscas, foram encontradas as várias porções de cocaína e maconha, e também os 3.000 microtubos vazios.

Não há como negar que os réus foram surpreendidos em típica situação de flagrante delito, enquanto vendiam entorpecentes, e ainda mantinham em depósito a droga que restou apreendida. É certo que os réus não foram vistos ingressando no interior do galpão, em razão da posição em que os policiais civis permaneceram durante a campana. Contudo, a partir da simples análise das fotos (fls. 226/230) e vídeos juntados pela defesa, não se concluir que se tratasse um imóvel totalmente inexpugnável, até mesmo porque, na data dos fatos, os policiais lá ingressaram até mesmo com certa facilidade, pois não se recordaram que se portão encontrava aberto ou trancado. Se o prédio permitiu o fácil ingresso de mais de um policial no seu interior naquela data, certamente os réus também o fizeram para pegar a droga que estavam vendendo pela via pública. Caso fosse totalmente impossível ingressar no

local em razão dos muros, portões e sistema de vigilância, os policiais teriam sido obrigados a arrombar eventuais obstáculos, ou então entrar em contato com os responsáveis pelo barracão, não havendo notícias de que tais providências tenham sido necessárias durante a diligência. Também não se duvida de que o réu Herbert seja o proprietário de um pequeno bar anexo à sua residência. Os documentos e fotos de fls. 217 e seguintes são bastante claros nesse sentido. Contudo, tal fato, diante de tudo o que foi apurado, não o exime de sua responsabilidade penal, pois, conforme dito, foi visto em plena prática do tráfico, agindo em concurso com o réu Marcelo, que já era conhecido nos meios policiais como traficante. Também chama a atenção o fato de que o tráfico, naquela data, era realizado de maneira aberta, visto que, além dos policiais civis, policiais militares também foram acionados a comparecer no local, em razão de suspeitas de que dois indivíduos estivessem vendendo drogas naquela oportunidade.

Nota-se, portanto, que a prova produzida no inquérito é ratificada na instrução processual é conclusiva e indica, com segurança, a traficância. Vale deixar consignado, de início, que a prova oral colhida por meio dos depoimentos dos policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso ora em exame. Além disso, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que tem o direito de alegar o que quiserem, uma vez que não são obrigados a produzir provas contra si mesmos.

Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP - Apel.185.484-3; d.j. 22.06.95).

"Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário (TJSP Apel. 0082698-64.2010.8.26.0050; d.j.11/04/13).

No caso em questão, os depoimentos dos policiais, como já dito, são firmes e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, tampouco supor que pretenderam acusar os réus falsamente pela prática de crime tão grave. No caso, inclusive, os policiais sequer conheciam o réu Herbert.

A condenação, portanto, é medida de rigor.

Na dosimetria das penas, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

O acusado Herbert Rafael Corveloni Pedroso, conforme certidão de fls. 30, é primário e não possui antecedentes. Contudo, a quantidade de droga apreendida, mais de 05 Kg de maconha, e 285 gramas de cocaína, justifica a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, temos que o réu, além de ser primário e de bons antecedentes, não era conhecido até então nos meios policiais, e não há notícias de seu envolvimento com organizações criminosas, de modo que, nos termos do §4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, reduzo a sua pena em 1/2, considerando, para tanto, a natureza extremamente nociva de parte do entorpecente apreendido - a cocaína -, totalizando 02 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa, diária no mínimo legal.

Na aplicação de regime, curvo-me aos argumentos lançados no HC.118.533, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, julgado no dia 23 junho de 2016 para, nos casos de tráfico privilegiado, afastar a hediondez da conduta e, por conseguinte, fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Ademais, segue o entendimento jurisprudencial manifestado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade. Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Réu que preenche todos os requisitos exigidos para redução da pena (art. 33, § 4º) Redutor que deve ser aplicado em metade - Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade (PPL) por restritivas de direitos (PRD) e fixação do regime aberto Recurso parcialmente provido - (voto n. 31635).

(Relator(a): NewtonNeves; Comarca: Fernandópolis; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/03/2017; Data de registro: 06/04/2017).

Ainda, com fulcro no mesmo entendimento, nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena corporal por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, a ser determinada em sede de execução, além do pagamento de outros 10 dias multa, diária no mínimo legal.

Fixo, para início do cumprimento da reprimenda o regime aberto, em caso de descumprimento das penas aplicadas.

Já o réu Marcelo Henrique Romanelli Zerbo, conforme certidão de fls. 33/34, responde a outra ação penal também pela prática do tráfico de drogas (autos n. 1501595-50.2021), mas não conta com condenações definitivas que o tornem reincidente, ou portador de maus antecedentes. Contudo, repita-se, a considerável quantidade de droga apreendida justifica, nesta fase, a fixação da pena base em 1/6 acima do mínimo legal, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, impossível a aplicação do disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11343/2006, considerando a existência de outros processos em andamento envolvendo o tráfico, e ante a existência de dedicação a atividades criminosas, conforme relato dos policiais.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I (...). III - Quanto ao tráfico privilegiado, o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - In casu, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente é reincidente, não preenchendo, portanto, o requisito legal da primariedade para o privilégio. V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe26/10/2020).

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena, contudo, deverá ser o semiaberto, por conta do que determina o artigo 33, parágrafo 2, letra "b", do Código Penal.

O artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação conferida pela Lei 11.464/07 - que determina que o condenado pela prática de crime hediondo inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade, necessariamente, no regime fechado - foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 27.06.12, ao julgar o HC 11.840, Relator o Ministro Dias Toffoli. Naquela ocasião, nossa Corte Constitucional destacou que, mesmo na hipótese de condenação por tráfico de entorpecentes, o regime inicial do cumprimento de pena não é mera decorrência do quantum da reprimenda ou da natureza hedionda do delito, estando condicionado também à análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. O regime inicial fechado revela-se possível, destarte, em condenações por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 08 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, o que não ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:

"STF-0036402) HABEAS CORPUS. JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR. IMPUGNAÇÃO. A teor do artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. Pena. Regime de cumprimento. Concessão da ordem de ofício. Em face do disposto no § 2º, alínea "b", e no § 3º do artigo 33 do Código Penal, em se tratando de condenado não reincidente, cuja pena tenha ficado no mínimo previsto para o tipo e situada entre quatro e oito anos, mostra-se possível o cumprimento, desde o início, em regime semiaberto, sendo desinfluyente a circunstância de haver a prática de tráfico de entorpecentes, ante o fato de o Plenário do Supremo ter declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07. Habeas Corpus nº 111.840/ES, da relatoria do ministro Dias Toffoli, julgado em 27 de junho de 2012. (Habeas Corpus nº 112.835/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Marco Aurélio. unânime, DJe 13.06.2013);

"STJ-0575850) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "B" E 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pautou-se nas circunstâncias do caso concreto, entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a acusada não se dedicaria a atividades delituosas, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência essa que é vedada em recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como a agravada era tecnicamente primária ao tempo do delito, possuidora de bons antecedentes, teve a reprimenda-base fixada no mínimo legal, foi beneficiada com a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e foi definitivamente condenada à reprimenda de 4 anos e 2 meses de reclusão, o regime inicial semiaberto é, efetivamente, o que se mostra o mais adequado no caso, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e 3º, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (grifei). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial nº 1.362.050/MG (2013/0016179-7), 6ª Turma do STJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz. j. 17.11.2015, DJe 02.12.2015).

A quantidade da pena imposta também impede a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

- A) condenar MARCELO HENRIQUE ROMANELLI ZERBO à pena de 05 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento 583 de dias-multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06;
- B) condenar HERBERT RAFAEL COVERLONI PEDROSO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 anos e 11 meses, em local e horários a serem definidos em sede de execução, bem como ao pagamento de 301 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O réu Marcelo, uma vez condenado, e diante da constatação de seu reiterado

envolvimento com o tráfico, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da prisão cautelar, já indicados quando de sua prisão em flagrante.

Recomende-se.

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu Herbert em favor da União, devendo a quantia ser revertida ao FUNAD, após o trânsito em julgado, uma vez provada sua origem ilícita. Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA